

1502556-10.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HERBERT CLAYTON DA SILVA SARAGOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

HERBERT CLAYTON DA SILVA SARAGOSA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 02 de agosto de 2021, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502556-10.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502556-10.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HERBERT CLAYTON DA SILVA SARAGOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

HERBERT CLAYTON DA SILVA SARAGOSA foi denunciado pelo Ministério Público, como

incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 02 de agosto de 2021, por volta das 01h35, na Avenida Clodoaldo Amaral, nº 245, Trevo, nesta Comarca, trazia consigo substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi citado e notificado, apresentando defesa prévia (fls. 107/108). Recebida a denúncia (fls. 109).

Durante a instrução foi ouvida testemunha e realizado o interrogatório (fls. 117/118).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (fls. 137/143) e a defesa a absolvição ante a ilicitude e insuficiência da prova (fls. 1148/163).

É o relatório.

DECIDO.

Verifica-se dos autos que guardas civis metropolitanos, em patrulhamento de rotina, visualizaram o réu em suposta atitude suspeita e resolveram abordá-lo, ocasião em que, em revista pessoal, foi apreendido pote plástico no interior de suas roupas íntimas, contendo porções de droga, sendo, então, detido em flagrante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11343/06.

Diante da mecânica dos fatos, patente a ilicitude da prova da materialidade do delito e, conseqüentemente, da autoria dos eventuais atos penalmente ilícitos. Como se sabe, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 144, § 8º, atribuiu às guardas municipais a tarefa de proteção aos bens, serviços e instalações do Município, não as fazendo, pois, auxiliares da Polícia Militar e nem lhes conferiu função repressiva dos crimes, e, dessa forma, as guardas municipais só podem existir se destinadas à proteção dos bens, serviços e instalações do Município, não lhes cabendo, portanto, os serviços de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, de polícia judiciária e de apuração das infrações penais (TJ/SP - Apelação Criminal n. 288.556-3 - Indaiatuba - 7ª Câmara Criminal - Rel. Des.: Celso Limongi - j. 22.02.00; TJ/SP); aliás, essas competências foram essencialmente atribuídas pela Constituição Federal às polícias militar e civil.

Dessa forma, "guardas civis municipais não têm, portanto, competência legal para desenvolver ação pertinente à segurança pública, como policiamento preventivo, atividade, repita-se à exaustão, por expressão previsão constitucional, exclusiva das forças policiais. Nos termos da redação do § 8º do artigo 144 da Constituição da República, incumbe aos guardas municipais somente a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, conforme dispuser a lei, enquanto que, segundo disposto no caput do artigo 144, a segurança pública deve ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo atribuição exclusiva das polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, polícias civis, militares e dos corpos de bombeiros militares. A auxiliar na compreensão e interpretação desse texto legal, insta realçar o ensinamento do Professor José Afonso da Silva no sentido de que a segurança pública constitui atividade de competência e responsabilidade exclusiva de cada unidade da Federação, de acordo com o disposto no artigo 144, §§ 4º, 5º e 6º. Acerca da competência das guardas municipais, esclarece o autor: "Os constituintes recusaram várias propostas no sentido de instituir alguma forma de polícia municipal. Com isso, os Municípios não ficaram com nenhuma específica responsabilidade pela segurança pública. Ficaram com a responsabilidade por ela na medida em que sendo entidade estatal não pode eximir-se de ajudar os estados no cumprimento dessa função. Contudo, não se lhes autorizou a instituição de órgão policial de segurança e menos ainda de polícia judiciária. A Constituição apenas lhes reconheceu a faculdade de constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Aí certamente esta uma área que é de segurança pública: assegurar a incolumidade do patrimônio municipal que envolve bens de uso comum do povo, bem de uso especial e bens patrimoniais" (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0000022-23.2014.8.26.0631, 1ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Márcio Bartoli, j. 09/05/16).

Nem se alegue a edição da Lei nº 13.022/14 para justificar e legitimar os atos supra mencionados, pois tal ato legislativo foi editado para regulamentar o art.

144, § 8º, da CF e, assim, como se sabe, por se tratar de regra hermenêutica constitucional elementar, as normas infraconstitucionais regulamentares não podem alargar o âmbito de competências estipuladas pela norma constitucional, que não concedeu à guarda municipal qualquer atuação em matéria de segurança pública, razão pela qual, enquanto agentes administrativos, regidos pelo princípio da legalidade, só podem atuar aonde a lei autoriza.

Daí que a falta de previsão constitucional implica verdadeira vedação de agir na esfera de serviços de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, de polícia judiciária e de apuração das infrações penais (TJ/SP - Apelação Criminal nº 0007989-92.2015.8.26.0564, 1ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Márcio Bártoli, j. 29.02.16); portanto, "de fato, a busca e apreensão de entorpecentes não está entre as funções delegadas à guarda municipal pela Carta Magna (artigo 144, § 8º, da Constituição Federal)". (TJSP. 16ª Câmara Criminal. HC nº 2016545-19.2020.8,26.0000. Rel. Otávio de Almeida Toledo. j. 04/08/20).

Inegável, pois, que os guardas civis metropolitanos não tinham - e não têm ! - competência legal e não estavam investidos de autoridade para efetuar abordagem e fazer a revista pessoal no réu e, conseqüentemente, fazer a apreensão das drogas (TJ/SP - Apelação Criminal n. 290.558-3 - Piracicaba - 7ª Câmara Criminal - Relator: Gomes de Amorim - 12.01.00 - V.U.), inclusive porque sequer testemunharam atos criminosos sendo praticados, mas, apenas, faziam patrulhamento de rotina, quando, então, visualizaram o réu em suposta atitude suspeita e realizaram sua abordagem, exercendo, pois, verdadeira atividade de polícia judiciária ao realizarem busca pessoal decorrente de atitude suspeita do acusado.

Por outro lado, nem se alegue que em decorrência do poder de prender qualquer um em estado de flagrância, nos termos do art. 301 do CPP, estaria a guarda municipal ou qualquer cidadão autorizado a efetuar buscas pessoais e apreensões, por se tratarem de coisas absolutamente diversas.

Uma coisa é a prisão em flagrante - disciplinada pelos arts. 301 a 310 do CPP - que pode ser realizada por qualquer do povo. Outra a diligência de investigação para apuração de infração penal, bem como a busca (pessoal) e apreensão - disciplinada pelos arts. 240 a 250 do CPP - que somente pode ser realizada por autoridade pública devidamente competente para o ato (v. PITOMBO, Cleunice Bastos, Da Busca e Apreensão no Processo Penal, 2ª ed., São Paulo: Ed. RT, p. 183 e sgts.).

Na verdade, a questão foi invertida, pois não houve a prisão em flagrante e depois a busca pessoal com a apreensão das drogas; ao contrário, primeiro houve a diligência de busca pessoal e apreensão das drogas e, posteriormente, a prisão em flagrante, inclusive porque nenhum dos guardas municipais testemunharam a prática de crime ou perseguiam o réu em razão de prática de ilícito, mas apenas "desconfiaram" dele e, em razão de tal desconfiança, houve a busca pessoal com apreensão das drogas, o que, então, gerou a prisão em flagrante do réu.

Nesse sentido:

"A dinâmica dos fatos aqui tratados evidencia que a conduta dos guardas municipais atuantes no caso não restou amparada pelo artigo 301 do Código de Processo Penal. Afinal, a prisão da ora apelante não decorreu de situação flagrancial presenciada pelos agentes públicos no desempenho de sua atuação ordinária. Pelo contrário, como visto, ao depararem com a acusada na via pública, os sentinelas não tinham conhecimento do que ela trazia consigo ou guardava, sendo certo que a descoberta de estupefaciente resultou de posterior exame, de revista à apelante (corporal, portanto), típica de policiamento preventivo/ostensivo, normalmente afeto à Polícia Militar, algumas vezes desempenhado pela Civil. A atividade averiguatória levada a efeito pelos servidores públicos da Urbe conflitou com o papel constitucional da Guarda Municipal, tarefa primordialmente voltada à segurança patrimonial. Como cediço, segundo o artigo 144, § 8º, da Lei Maior, incumbe-lhe a função de proteção dos bens, serviços e instalações municipais." (TJ/SP - Ap. nº 1505992-59.2020.8.26.0132. 5ª C. Crim. Rel. Des. Geraldo Wohlers. j. 08/11/2021).

"Prova criminal ilícita. Ocorrência. Apreensão de crack. Busca pessoal realizada por guardas municipais. Exorbitância da esfera de competência. Inteligência do art. 144, §8º, da cf. Apreensão nula. Comprometimento da certeza da materialidade da infração. Absolvição mantida. Recurso não provido. Realizada por quem não tem

competência legal, a busca resulta em apreensão nula, que não serve para provar posse de droga e compromete a certeza da própria materialidade da infração" (TJ/SP - Apelação nº 198.513/3, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dante Busana, j. 07/03/1996);

"Revisão Criminal. Roubo qualificado. Abordagem do réu por Guardas Municipais. Existência de prova a contaminar a ação penal. Impossibilidade de realização pela Guarda Municipal de atos privativos das Polícias Judiciária e Militar. Pretensão absolutória acolhida Apelo provido" (TJ/SP - Revisão Criminal nº 0162917-15.2013.8.26.0000, 1º Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Almeida Sampaio, j. 04/04/14);

"TÓXICO - Uso próprio - Apreensão da droga resultante de busca pessoal realizada por guarda civil municipal, sem competência para tanto - Artigo 144, § 8º, da Constituição da República - Ineficácia - Absolvição decretada - Recurso não provido" (JTJ 184/312);

"PROCESSO-CRIME - Nulidade - Ocorrência - Guardas Municipais que ingressaram no domicílio dos Apelantes de madrugada, procederam à revista e apreenderam entorpecente e armas, sem ordem judicial - Falta de poder de polícia para tal ato - Artigo 144 da Constituição Federal que outorgou exercício da segurança pública à Polícia Civil e Militar - Guarda Municipal destinada tão-só à proteção dos bens, serviços e instalação do Município, conforme dispuser a lei - Coação ilegal existente - Habeas Corpus concedido de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. Guarda Municipal é guarda de patrimônio público municipal e não está investida de funções de natureza policial e dar busca pessoal em quem quer que seja" (TJ/SP - Apelação Criminal n. 269.826-3 - 4ª Câmara Criminal - Rel. Des. Bittencourt Rodrigues - j. 24.08.99);

"TÓXICO - uso próprio - Absolvição - Necessidade - Droga apreendida por guarda municipal - Apreensão realizada sem a presença de testemunhas - Propriedade negada pelo acusado - Guarda municipal, ademais, que não é investido de autoridade para a realização de busca pessoal - Recurso provido" (TJ/SP - Apelação Criminal nº 290.558-3 - Piracicaba - 7ª Câmara Criminal - Rel. Des. Gomes de Amorim - j. 12.01.00).

Dessa forma, patente que a própria prisão em flagrante estava nula, já que decorrente de diligência ilegal, qual seja, a busca pessoal no acusado por autoridade incompetente, inclusive porque a prova obtida por meio de revista pessoal realizada por guarda municipal é ilegítima, por ausência de autorização legal, contaminando tudo que dela derivou (TACRIM/SP - Apelação Criminal nº 1.270.983-9 - Santos - 4ª Turma - rel. Marco Nahum - j. 18.09.2001; TJ/SP - Apelação Criminal nº 938.307.3/7; TJ/SP - Apelação Criminal nº 1.070.364.3/0).

Ademais, não custa ressaltar que o "excesso de função" praticado pela guarda municipal não se justifica mesmo com a apreensão das drogas, pois "a ilegalidade do ato praticado, além de eticamente inadmissível, não se transmuda em ato lícito, ainda que em detrimento da apuração da verdade, porque ofende um direito fundamental da pessoa humana, valor que, proporcionalmente, se sobrepõe ao interesse da sociedade no combate ao crime. "É um pequeno preço que se paga pô viver-se em Estado Democrático de Direito" (ALEXANDRE DE MORAES, Direito Constitucional, 4ª edição, revista e ampliada, São Paulo: Editora Atlas S.A., 1998, p. 110)" (TACRIM/SP - Apelação Criminal nº 1.270.983-9 - Santos - 4ª Turma - rel. Marco Nahum - j. 18.09.2001).

Dessa forma, ante o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal realizada no acusado e da apreensão das drogas, com a consequente contaminação da própria prisão em flagrante, alternativa não resta a não ser absolver o réu ante a ausência de comprovação do crime, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Ante o exposto, ABSOLVO o réu HERBERT CLAYTON DA SILVA SARAGOSA, qualificado nos autos, da imputação que lhe é feita, nos termos do art. 386, II, do CPP, arquivando-se os autos.

Havendo bens apreendidos, providencie-se a restituição e/ou doação/destruição. Sem custas processuais.

P.R.I.C.

Praia Grande, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA